

1503287-43.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2036631/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 11020247 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 13727/20/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2036631 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

DANIEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503287-43.2021.8.26.0071 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503287-43.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2036631/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 11020247 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 13727/20/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2036631 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

DANIEL GUSTAVO AMARAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

DANIEL GUSTAVO AMARAL foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 13 de novembro de 2.020, por volta das 11h25, na Alameda Copérnico, quadra 02, Parque Jaraguá, nesta cidade, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 5,02 gramas de cocaína, divididos em 26 porções, droga que determina dependência física e psíquica, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 40), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 45/46.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 11 de junho de 2021 (fls. 47/49).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e foi decretada a revelia do réu, que não compareceu (fls. 65/80).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 84/87).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 91/116, alegando que: 1)- não havia delação ou investigação prévia apontando o réu como traficante; 2)- ele não foi visto dispensando as drogas ou as manuseando; 3)- o réu afirma ser verdade que mexia no tablado, pois acreditava que ali teria derrubado alguma coisa; 4)- nenhum usuário estava perto; 5)- o réu estava caminhando e não parado, o que evidencia conduta incompatível com a espera de consumidores de droga; 6)- não se pode falar em inversão do ônus da prova, impondo ao réu o dever de provar que não cometeu o crime; 7)- eventualmente, deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pediu a absolvição e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 08 e pelo laudo pericial de fls. 11/13 (vinte e seis porções de cocaína com peso de 5,02 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Ouvido na polícia, ele declarou que estava na Alameda Copérnico, dirigindo-se ao seu trabalho. Parou perto de uns tablados de madeira que havia na rua, por achar que teria caído algo de seu bolso. Foi coisa rápida. Ao agachar, notou que nada havia caído e continuou andando. Não viu a viatura da polícia militar. De repente, a viatura o parou e os policiais passaram a dizer que ele guardava e vendia drogas. Os policiais o revistaram e acharam seu dinheiro, R\$ 48,50, fruto de seu trabalho e também do auxílio emergencial. Em seguida, eles o levaram até os tablados, ali mexeram e retiraram tudo do chão. No meio dos tablados, "bem embaixo", havia pinos. Os policiais disseram que se tratava de droga. Nada tem a ver com o entorpecente (fls. 14).

Em juízo, a testemunha João Henrique Coutinho de Souza, policial militar, afirmou que realizava patrulhamento e, ao passar por um cruzamento da Alameda Copérnico, viu o réu agachado, próximo a alguns "palets", aparentando esconder algum objeto. Os policiais resolveram abordá-lo. O acusado notou a presença da equipe policial e saiu em sentido contrário ao da viatura. Durante a busca pessoal, nada de ilícito havia em poder do réu. Ele tinha apenas a quantia de cerca de R\$ 85,00. Os policiais seguiram até o local onde o viram agachado e mexendo em algo e, ali, dentro de um pacote de salgadinho, encontraram vinte e seis pinos de cocaína. Indagado sobre a droga, ele negou que estivesse mexendo nela e também que o material lhe pertencia. Inicialmente, viu-se apenas que o acusado aparentava estar escondendo algo, mas não foi possível saber do que se tratava. Ele estava agachado e colocando algo nos "palets", na calçada. Os "palets" estavam na calçada. Não o conhecia anteriormente. Fazia patrulhamento de rotina (fls. 71/74).

A testemunha Luis Paulo dos Santos Quintanilha, também policial militar, relatou que fazia patrulhamento com seu parceiro de viatura, o policial João. No local do fato, ponto conhecido pela prática de tráfico, avistou o réu abaixado, mexendo em algo situado atrás de "palets" de madeira. Os "palets" estavam na calçada. Decidiu pela abordagem. O acusado notou a presença da viatura, levantou-se e começou a caminhar pela via pública, mas acabou abordado. Em poder dele, havia quarenta e oito reais e cinquenta centavos, em cédulas e moedas. No local onde o acusado mexia, havia um pacote de salgadinho contendo vinte e seis pinos de cocaína prontos para a venda. Indagado, o réu negou a posse do entorpecente. Ele apresentou versões desconexas. O réu foi abordado no mesmo quarteirão em que estava o entorpecente,

alguns metros à frente (fls. 76/79).

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa que sustentam o contrário.

A prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, segundo os quais o réu foi inicialmente avistado agachado, guardando algo em "palets" que estavam na calçada, em local conhecido como ponto de tráfico. Outrossim, prosseguiram os policiais afirmando, o acusado notou a aproximação da viatura, levantou-se e saiu caminhando em sentido contrário àquele no qual eles vinham. Disseram os agentes públicos, mais, que, em meio aos "palets", onde o réu mexia, foram encontrados vinte e seis pinos de cocaína e, na revista pessoal, foi achada a quantia de R\$ 48,50.

As afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Não bastasse, a experiência tem demonstrado que, quando arroladas como testemunhas de tráfico pessoas de fora dos quadros da polícia, elas invariavelmente não dizem a verdade em juízo, pois não querem se expor a delatar publicamente um traficante, possivelmente com medo de eventuais represálias, ou mesmo por terem algum vínculo de intimidade ou amizade com a pessoa processada.

Não é verdade que o acusado agachou-se para verificar se algo havia caído de seu bolso.

Fosse isso verídico, ou algo teria sido encontrado caído em meio aos "palets", ou esse objeto ainda deveria estar no bolso do acusado.

Ocorre que nem uma coisa e nem outra se comprovou.

Assente-se, no particular, que, no boletim de ocorrência de fls. 06/07 e no auto de apreensão de fls. 08, não se verifica que a apreensão tenha recaído em algum outro item que pudesse ter estado no bolso do acusado e caído ou mesmo ali permanecido. Prosseguindo, a afirmação do réu, no sentido de que os policiais retiraram tudo do chão e revistaram os "palets", vindo a encontrar, "bem embaixo", os pinos de cocaína, não é verossímil.

Afinal, não houvesse uma indicação específica de que ali havia droga (indicação essa que decorreu do fato de o réu ter sido visto agachado no local, aparentando estar escondendo algo), certamente os policiais não teriam efetuado a revista que resultou na apreensão do entorpecente.

Imagine-se se policiais militares, mesmo sem qualquer suspeita ou notícia pontual, dedicassem-se a revistar todos os "palets" ou materiais espalhados pelas calçadas da cidade, à cata de entorpecente.

Se agissem assim, não teriam tempo para desempenhar outras atividades em suas jornadas de trabalho ou mesmo para realizar patrulhamento preventivo e ostensivo.

Enfim, os policiais somente efetuaram a revista no local e apreenderam a droga

porque, momentos antes, notaram o acusado ali presente em atitude suspeita.

Por outro lado, outras circunstâncias do caso também indicam não somente que o réu era o responsável pelas porções de cocaína mas também que as destinaria a

terceiros.

Com efeito, quando avistado, ele não estava em deslocamento, mas sim abaixado, mexendo em "palets" como se estivesse a esconder alguma coisa.

E, quando o réu notou a aproximação da viatura policial, logo levantou-se e passou a andar em sentido contrário ao dos policiais.

Trata-se de atitude típica de quem está cometendo o ilícito previsto no artigo 33 da Lei n. 11343/2006, mormente se se considerar que o agente trazia consigo dinheiro (R\$ 48,50) e que, no local onde ele mexia, foram encontrados vinte e seis pinos de cocaína (embalados de forma própria ao comércio no varejo).

Saliente-se que usuário algum é surpreendido escondendo tal quantidade de droga em "palets" situados numa calçada.

Se se tratasse, enfim, de mero consumidor de entorpecente, o réu teria guardado o material em sua casa.

A guarda em plena via pública somente se justifica se se tiver em vista que ele exercia ou pretendia exercer o comércio espúrio de rua.

Na mesma ordem de ideias, não é possível levar a sério a alegação de que o acusado não foi flagrado em poder da droga.

Se nada mais foi achado em meio aos "palets", a única conclusão possível é no sentido de que o réu agachou-se e foi o responsável por esconder os pinos de cocaína.

Cabe ainda observar que, embora ele tenha dito que o dinheiro adveio de seu trabalho e do auxílio emergencial, nada comprovou a respeito.

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a guarde, traga consigo e a tenha em depósito (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Ao contrário, deve o réu ser condenado pelo tráfico de drogas.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu é primário e não registra antecedentes (fls. 33).

Diante disso, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Deve ser aplicado o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Destaque-se que as quantidades de droga e de dinheiro apreendidas não eram das mais elevadas, não sendo possível inferir, a partir daí, que o réu se dedicava a atividade criminosa.

Frise-se que nenhum elemento de convicção permite conclusão no sentido de que o acusado integrava organização criminosa ou era indivíduo dedicado a atividade criminosa.

Cabível o privilégio, deve-se dizer que se afigura justo diminuir a pena no grau máximo de dois terços, tendo em vista que as quantidades de drogas e de dinheiro apreendidas não foram das mais elevadas.

Destarte, a pena resulta em um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para o tráfico, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Ainda, no julgamento do Habeas Corpus nº 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim

dissertou:

"Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado para o tráfico, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção.

Considerando as circunstâncias expostas (primariedade, ausência de antecedentes, pequenas quantidades de droga e dinheiro), fixa-se o regime inicial aberto.

Levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, e, ainda, o fato de as quantidades de droga e de dinheiro não serem das mais elevadas, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Daniel Gustavo Amaral como incurso nas penas do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

P.R.I.

Bauru, 06 de julho de 2022.

MARGEM DIREITA